

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO - Ausencia de ilicitud sustancial.

Asesoramiento ilegal consistente en la elaboración de un recurso de reconsideración contra la resolución sanción No. 252412012000001 del 27 de noviembre de 2012 presentado por la empresa Cooperativa de XX y la Guajira XXX.

En el computador que tienen asignado los funcionarios en Puerto Bolívar Cerrejón para el cumplimiento de sus funciones, apareció un proyecto de recurso de reconsideración que con posterioridad fue radicado por la empresa Cooperativa de Transportes el Cesar y la Guajira.

El disciplinado fue absuelto toda vez que después de analizar la probatoria obrante al interior de la investigación, se observó por parte de esta Subdirección la presencia de pruebas encontradas que inexorablemente generan dudas insuperables respecto de la ocurrencia del hecho. En tal sentido pudo establecerse que se encontraron elementos suficientes para resolver la actuación a favor del disciplinado en virtud del principio de In dubio pro disciplinado, teniendo en cuenta que con el material probatorio recolectado, fue imposible superar las dudas sobre la autoría de la infracción disciplinaria.

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 5 y Art 48.1 CDU y 421 CP

FALTA DISCIPLINARIA / ESTRUCTURA – Infracción del deber funcional.

“... en materia disciplinaria la falta se estructura a partir de la infracción del deber funcional, va que no es el simple desconocimiento del deber el que origina la falta disciplinaria, pues quienes ejercen la función pública, deberán desempeñar su empleo, cargo o función consultando en forma permanente los intereses del bien común, teniendo siempre presente que los servicios que prestan constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y no liberalidad del Estado.

Por ende, entonces, la falta disciplinaria debe estar objetivamente demostrada y corresponder la adecuación de la conducta del implicado o implicados, a la descripción legal de la irregularidad que se imputa, principio de legalidad y así mismo, su carácter antijurídico derivado de la infracción del deber funcional sin justificación alguna, ilicitud sustancial.”

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 5

ANTI JURIDICIDAD / EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. No está probada la presencia en el lugar de los hechos investigados

“...Así pues, la decisión que se permite adoptar el Operador, es la absolución en favor del disciplinado, teniendo en cuenta que el Despacho carece del convencimiento respecto de la autoría de la infracción disciplinaria. Lo anterior, apelando a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, el cual establece que durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2013-006

resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla. En el caso sub examine y teniendo en cuenta los razonamientos planteados, no existe prueba que dote de certeza al operador respecto de la autoría de la infracción disciplinaria, ello en atención de las especificidades que se presentaron en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos.”.

FUENTE FORMAL – LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 9 y 28

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2013-06
Número y fecha del fallo:	17413-021, del 30 de julio de 2013
Asunto:	Fallo de Primera Instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Se procede a proferir fallo de primera instancia dentro del expediente administrativo disciplinario No. 1704-01-20012-01, seguido en contra de (XXXX).

CASO CONCRETO

ANÁLISIS Y LA VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS CARGOS, DE LOS DESCARGOS Y DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El pliego de cargos que se formuló al disciplinado constituye una imputación diáfana, de suerte tal, que una vez proferido, el disciplinado contó con la posibilidad de ejercer su derecho de defensa respecto de una conducta en concreto. En tal sentido, encuentra el operador abastecidos los requisitos para definir jurídicamente la actuación disciplinaria.

El cargo formulado al investigado fue el siguiente:

“El señor XXXX, en calidad de funcionario de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha, presuntamente elaboró los días 18 y 19 de diciembre de 2012, a favor de la empresa Cootracegua, el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución Sanción No. 252412012000001 del 27 de noviembre de 2012.

El comportamiento imputado al señor XXXX, corresponde a un asesoramiento sobre un asunto administrativo aduanero; conducta que se adecuía a la falta disciplinaria consagrada en el artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, por cuanto presuntamente realizó objetivamente y a título doloso la descripción típica de la disposición prevista en el artículo 421 del Código Penal”.

Para el censor de instancia, la imputación formulada fue suficientemente clara, al punto, que el disciplinado contó con la posibilidad de ejercer su derecho de defensa respecto de una conducta específica y determinada. Igualmente, en la valoración jurídica de la conducta, se precisó que el

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2013-006

comportamiento se adecuaba al tipo disciplinario consagrado en el numeral primero del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el cual por ser un tipo en blanco, encuentra su complemento en el estatuto penal, y para el caso concreto, se corresponde con el artículo 421 del referido estatuto.

De otra parte, se advierte que la imputación obedeció a un ejercicio argumentativo, se fundamentó en pruebas y en las disposiciones normativas aplicables para el caso sub examine. Frente a la imputación, el disciplinado presentó memorial de descargos en virtud del cual esgrimió razones defensivas y solicitó la práctica de algunas pruebas, las cuales fueron concedidas y practicadas parcialmente. Igualmente, el Dr. YYYY, presentó alegatos de conclusión, brindando sus argumentaciones finales frente al caso sub examine.

Una vez agotada la actuación procesal, y acogiendo los argumentos expuestos por la defensa, este Despacho carece de convencimiento dotado de certeza para atribuir responsabilidad disciplinaria al señor XXXX, razón por la cual, se advierte desde este punto, que el sentido de la presente decisión será la absolución del imputado, acogiendo algunos de los argumentos expuestos por la defensa técnica y material.

Teniendo en cuenta el sentido de la decisión, entiéndase efectuado el pronunciamiento respecto de los descargos y alegatos de conclusión, con el análisis subsiguiente:

Se estructura en el caso sub examine una duda razonable cuyos cimientos estructurales descansa en 9 pilares argumentativos:

i) La fecha de creación y modificación del archivo no significa que el documento haya sido elaborado el 18 y 19 de diciembre de 2012.

Resulta perfectamente admisible que el documento haya sido creado con antelación al 18 de diciembre de 2012, incluso, en un equipo informático diferente al utilizado en la Oficina de la DIAN en Puerto Bolívar Cerrejón e inoculado en el equipo mediante la utilización de un disco extraíble USB.

Estando presente esta posibilidad, se afecta la certeza respecto de la fecha de elaboración del documento de marras y por ende del agente que lo elaboró.

ii) Durante los días 18 y 19 de diciembre de 2012, estuvieron comisionados 2 servidores públicos de la DIAN en Puerto Bolívar Cerrejón.

Al estar dos funcionarios de la DIAN comisionados para prestar sus servicios en Puerto Bolívar Cerrejón, los días 18 y 19 de diciembre de 2012, surge la primer y elemental duda. Cuál de los dos fue quien elaboró el documento, si se tiene en cuenta que, en principio, la asesoría ilegal es una conducta que no admite la coautoría.

Al haber dos funcionarios de la DIAN en Puerto Bolívar Cerrejón, sin tener certeza de la ubicación espacial de cada uno al interior de las instalaciones portuarias, sin conocimiento preciso de que tareas desarrollaron y el lugar en el cual las desempeñaron; genera una duda razonable e

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2013-006

insuperable; ya que cualquiera de los dos (SIOSI PINO y XXXX) pudo haber creado el archivo contentivo del documento pluricitado.

iii) No existe forma de establecer la ubicación espacial de los funcionarios XXX y XXXX, durante el tiempo en el cual estuvieron prestando sus servicios en Puerto Bolívar Cerrejón.

Es de resaltar en este punto, que conforme a las pruebas testimoniales y el mismo dicho del investigado, cuando hay dos funcionarios comisionados en el Cerrejón, es posible que no permanezcan juntos, ya que uno puede estar en la Barraca, otro adelantando inspecciones de Buques, otro en la oficina asignada a la DIAN o también se puede estar en el casino.

Así pues, al no conocerse la ubicación de los funcionarios XXXy XXXX al interior de Puerto Bolívar para los días 18 y 19 de diciembre de 2012, el operador no puede de manera caprichosa atribuir al señor XXXX su permanencia en la oficina para las horas y en los días en los cuales se creó y modificó el archivo de Word. Cabe anotar que esta es una duda insuperable en la investigación disciplinaria.

iv) La clave y el usuario de acceso al equipo informático ubicado en Puerto Bolívar no tenía niveles mínimos de custodia y seguridad.

La inspección administrativa efectuada en la oficina y al Computador asignado a los funcionarios de la DIAN en Puerto Bolívar Cerrejón, así como los testimonios que fueron analizados en precedencia, acreditaron de manera diáfana que el nivel de seguridad para acceder al equipo de cómputo de marras era nulo, ya que se contaba con usuario y clave única; datos que no eran resguardados con elementales condiciones de seguridad, de tal suerte que cualquier individuo que ingresara a la oficina, tenía la oportunidad de acceder al equipo y trabajar en él.

Las pruebas demostraron que el nombre del usuario y la clave, estaban en una gaveta del escritorio que permanecía sin llave, por lo que cualquier persona podía conocer los datos necesarios para acceder al equipo de cómputo y de tal manera hacer uso de este. Esta circunstancia genera una duda razonable en favor del disciplinado.

v) Diferentes personas tienen acceso a la oficina asignada a la DIAN en Puerto Bolívar.

Se logró probar que a la Oficina de la DIAN ubicada en Puerto Bolívar, ingresaban varias personas diferentes de los funcionarios de la contribución, como por ejemplo, personal de aseo, ingenieros de sistemas y personal del Cerrejón adscrito a la Oficina de Materiales.

Esta circunstancia, aunada a la posibilidad de que cualquier persona ingrese al equipo informático por la carencia de custodia del usuario y clave de acceso, hace probable que terceras personas hayan ingresado al computador, lo hayan manipulado mediante la creación, inoculación o modificación de archivos, circunstancia que genera una nueva duda probatoria respecto de la autoría del documento.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2013-006

vi) A parte de funcionarios de la DIAN, en el cerrejón hay personal que maneja el derecho aduanero.

Se logró probar que en las oficinas contiguas a la de la DIAN en Puerto Bolívar Cerrejón, esto es, la de Materiales, existe personal que maneja la operación aduanera. En tal sentido, se desvirtúa la hipótesis según la cual, los únicos conocedores del derecho aduanero en Puerto Bolívar, eran los funcionarios de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha. Circunstancia probada que admite la posibilidad de que otra persona (personal del Cerrejón) haya creado, modificado o incluso inoculado el archivo de marras en el Computador asignado a los funcionarios de la DIAN.

Es de resaltar que el conocimiento de asuntos relacionados con operación aduanera, no implica de plano, que se conozca el régimen sancionatorio aduanero, empero, existe la amplia posibilidad de que quien conoce y domina los temas concernientes a la operación, también maneje y conozca de derecho sancionatorio aduanero.

Como puede apreciarse, la circunstancia probada referente a la existencia de personal del cerrejón con conocimiento en derecho aduanero, admite la posibilidad de que terceras personas hayan creado, modificado o inoculado en el computador pluricitado el archivo contentivo del recurso de reconsideración. Por lo anterior, existen nuevos y mayores elementos de juicio para consolidar una duda razonable que debe resolverse a favor del disciplinado.

vii) No está probada la injerencia o el interés por parte del funcionario XXXX, respecto del trámite aduanero sancionatorio adelantado contra la Empresa XXX.

Como consecuencia de la solicitud probatoria que hiciere el disciplinado XXXX, este Despacho escuchó bajo la gravedad de juramento a todos los funcionarios de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha que tuvieron a cargo el expediente aduanero distinguido con el radicado No. AA 2012 2012 106. Estos testimonios demostraron que el investigado no consultó y tampoco mostró interés alguno por la investigación aduanera enunciada.

Igualmente, cuando el operador disciplinario adelantó inspección administrativa en Cootracegua, no se probó ningún vínculo o nexo entre la mencionada compañía de transporte con el señor XXXX.

En tales condiciones, al no demostrarse un interés por parte del aquí investigado respecto del proceso sancionatorio aduanero, carece el plenario de indicios o de elementos de juicio que demuestren la autoría del ilícito disciplinario.

viii) Existe duda respecto del conocimiento o dominio del derecho aduanero por parte XXX.

Al momento de proferir pliego de cargos al señor XXXX, el operador disciplinario concluyó que el señor XXX, además de ser la persona que reportó la existencia del documento objeto de investigación, no contaba con formación y experiencia en derecho aduanero, razón por la cual se ordenó la terminación y el consecuente archivo de la investigación.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2013-006

En etapa de juicio disciplinario y en el transcurso de la versión libre de XXXX, se allegó al proceso certificación de que el señor XXX era catedrático universitario y dictaba materias relacionadas con asuntos aduaneros. El señor XXX fue interrogado frente al particular y reconoció dar cátedra universitaria en ciertos temas aduaneros, haciendo la claridad de que manejaba sólo conceptos teóricos e históricos.

Así las cosas, el operador no tiene certeza absoluta de que el señor XXX desconozca totalmente el régimen sancionatorio aduanero, a pensar de que manifestara no conocerlo en su declaración juramentada, ya que en efecto dicta cátedra universitaria tratando temas teóricos de aduanas. Por lo anterior, no puede desecharse de plano la hipótesis según la cual es él el autor del recurso pluricitado.

ix) En el plenario no obran elementos de juicio y probatorios que desestimen la tesis planteada por la defensa, según la cual, XXXX pudo haber sido víctima de un “montaje” para ser inculpatado en la elaboración del recurso de reconsideración.

En efecto, todas las vicisitudes analizadas en precedencia, admiten la tesis según la cual, alguien pudo haber creado el archivo en el computador de marras con el propósito de perjudicar al disciplinado. Existiendo la probabilidad del suceso planteado por la defensa, se consolida un nuevo elemento generador de duda en favor del disciplinado.

En suma, desde el punto de vista probatorio está plenamente demostrado el hecho referente a la creación de un archivo virtual cuyo contenido corresponde con un recurso de reconsideración, que el mismo se creó y modificó en un computador asignado a funcionarios de la DIAN en Puerto Bolívar Cerrejón los días 18 y 19 de diciembre de 2012.

También, hay elementos de juicio que permiten inferir que la empresa XXX mintió en inspección administrativa respecto de la proyección y procedencia del recurso de reconsideración. No obstante, lo anterior, el operador carece de prueba y convencimiento más allá de toda duda razonable, respecto de la autoría del mencionado documento.

En conclusión, castigar al señor XXXX por su mera presencia física en el lugar de los hechos, de paso con duda respecto a la ubicación exacta del funcionario para los días 18 y 19 de diciembre de 2012 al interior de Puerto Bolívar; y por su idoneidad y pericia en materia aduanera, constituiría un ejercicio de responsabilidad objetiva, la cual en el marco de un estado social de derecho está proscrita por elementales razones de vulneración de derechos y garantías fundamentales.

Así pues, la decisión que se permite adoptar el Operador, es la absolución en favor del disciplinado, teniendo en cuenta que el Despacho carece del convencimiento respecto de la autoría de la infracción disciplinaria. Lo anterior, apelando a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, el cual establece que durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla. En el caso sub examine y teniendo en cuenta los razonamientos planteados, no existe prueba que dote de certeza al operador respecto de la autoría de la infracción disciplinaria, ello en atención de las

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2013-006

especificidades que se presentaron en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos.

OTRAS CONSIDERACIONES

El Despacho considera procedente oficiar a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha, con el propósito de que se establezcan control en la custodia y manejo de equipos informáticos, específicamente en la dependencia de la DIAN en Puerto Bolívar.

Igualmente, para que se evalúe la necesidad de permanencia de dos funcionarios en turno en Puerto Bolívar Cerrejón, toda vez que el volumen de diligencias reportadas para el mes de diciembre de 2012, en principio, no ameritan la permanencia de dos servidores de la contribución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO en favor de XXXX, quien se encuentra plenamente identificado en el aparte considerativo de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al Dr. XXXX, quien reportó como Dirección procesal el correo electrónico: XXX. Igualmente, comunicar al disciplinado el contenido de la presente providencia, señor XXXX, al correo institucional XXX. La presente notificación se surte en los términos del artículo 102 de la Ley 734 de 2002, conforme a solicitud expresa de la defensa.

TERCERO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede, en el efecto suspensivo, el **RECURSO DE APELACIÓN**, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los tres días siguientes a la notificación de la presente providencia.

CUARTO: INFORMAR, una vez en firme la presente decisión, a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 174 del Código Disciplinario Único.

QUINTO. EJECUTAR las acciones preventivas relacionadas en el aparte considerativo de la presente providencia.

SEXTO: LIBRAR por la Secretaría Técnica de esta Subdirección los oficios, correos y comunicaciones a que hubiere lugar.

JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso

Proyectó: Dr. Rodrigo Alejandro Rubio Gomez – Secretario Ad-Hoc
Aprobó: Dr. Jorge Adriano Moreno Ponce y Apoderado (a) del (os) investigado (s)